Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

Processo: 0842800-02.2020.8.12.0001
Autos: Procedimento Comum Cível
Autor: Vivani Gonçalves Vissoto Matos
Réu: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico

Vistos etc.

Trata-se de *Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais,* ajuizada por **Viviane Gonçalves Vissoto Matos,** em face de **Unimed Campo Grande/MS – Cooperativa de Trabalho Médico**, ambos já qualificados nos autos.

Narra a parte autora que é cliente da ré e foi diagnosticada com neoplasia da mama CID C50.9 em 05/12/2019, passando por uma mastectomia e ainda, necessitou passar por quimioterapia e radioterapia, cujos tratamentos foram autorizados pela ré.

Assinala que os procedimentos foram realizados conforme o protocolo ACT e a autora utilizada os medicamentos Zoladex e Tamoxifeno, todavia os mesmos não fizeram mais efeitos uma vez que a doença voltou a progredir, e considerando a ineficácia dos medicamentos o médico que assiste a autora prescreveu o medicamento "Ibrance na dose de 125mg ao dia" para uso contínuo.

Aduz que o referido medicamento é de alto custo, custando aproximadamente R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), não tendo a autora condições financeiras para pagar o referido medicamento, e que a ré negou o fornecimento do medicamento sob o argumento que o referido estava "fora da DUT". Narra que foi sendo requerido junta médica para avaliar o caso da autora, o que também foi negado pela ré.

Por tais fatos requereu a concessão de tutela de urgência para que a ré forneça imediatamente o medicamento Ibrance 125mg, uso contínuo, conforme prescrição Médica.

No mérito requer a procedência dos pedidos iniciais a fim de confirmar a tutela de urgência, condenando o réu ao fornecimento do medicamento Ibrance 125mg de acordo com a prescrição médica, bem como condena-lo ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais.

Juntou documentos de f. 12-38.

Pela decisão de f. 40-47, foram deferidas as benesses da justiça gratuita em favor da autora, bem como a tutela de urgência na forma pleiteada na inicial. Designou-se audiência de conciliação.

Audiência de conciliação realizada, porém sem acordo entre as partes (f. 267).

Citada, a ré apresentou contestação de f. 106-133, alegando

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/01/2022 às 22:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0842800-02.2020.8.12.0001 e código Yg3xQqOg.

preliminarmente, impugnação ao valor da causa, uma vez que o valor dado à causa é muito superior ao valor do medicamento pleiteado e do valor requerido a titulo de indenização por danos morais.

No mérito, aduz, em síntese, que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, acima mencionado, foi adaptado às disposições da Lei 9.656/98, assim, suas coberturas e obrigações são regulamentadas integralmente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, e que as coberturas obrigatórias, estas estão vinculadas ao taxativo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde - ANS vigente à época da solicitação, sendo que o medicamento requerido pela autora não está previsto no rol de cobertura mínima no Rol da ANS. Discorreu sobre a taxatividade do rol da ANS, bem como sobre a ausência de comprovação de que o caso da autora seja de natureza urgente e emergencial. Comentou, ainda, sobre a inocorrência de danos morais e inversão do ônus da prova. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Com a contestação foram juntados os documentos de f. 134-266.

Impugnação à contestação às f. 271-276.

Intimadas a indicarem as provas pretendidas, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (f. 296-297) e a parte requerida pugnou pelo depoimento pessoal da autora, prova testemunhal, prova documental e prova pericial indireta (f. 298-300).

Relatados. Decido.

Trata-se de *Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais,* ajuizada por **Viviane Gonçalves Vissoto Matos,** em face de **Unimed Campo Grande/MS – Cooperativa de Trabalho Médico**, ambos já qualificados nos autos.

Das provas requeridas pelas partes

Quanto ao pedido de depoimento pessoal da autora, indefiro-o, porquanto, tal prova se mostra inócua ao caso, já que as alegações autorais já constam na propria petição inicial, sendo desnecessária sua oitiva.

Em relação ao pedido de prova testemunhal, em que o requerido pugna pela oitiva de profissionais médicos, a fim de comprovar que o medicamento requerido pela autora pode ser substituído por outro coberto pelo plano de saúde, indefiro-o, uma vez que a análise quanto a possibilidade ou não de substituição do medicamento pode ser feita pelo próprio juízo, com base nos documentos colacionados aos autos, mormente considerando a existência de laudo e receituário médico, assinados por profissional devidamente registrado junto ao CRM.

No tocante à prova documental, indefiro-a, uma vez que incumbe ao réu especificar na contestação as provas que pretende produzir (art. 336, do CPC), além de que o requerimento de f. 298-300 foi feito de forma genérica, não sendo esclarecido quais os documentos relativos a direito ou fato superveniente que poderiam ser anexados aos autos e não o foram por ocasião da contestação.

No que concerne ao pedido de prova pericial indireta, através da qual

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/01/2022 às 22:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0842800-02.2020.8.12.0001 e código Yg3xQqOg.

o requerido pretende demonstrar que a negativa do medicamento decorreu do exercício legal de direito, uma vez que em consonância com a Resolução Normativa n. 428/2017, bem como informar quais outros medicamentos, presentes nas diretrizes de utilização do plano e que possuem previsão no rol de cobertura minima obrigatória, podem ser indicados ao tratamento da patologia que acomete a autora, indefiro-o, porquanto os documentos já anexados aos autos são suficientes para a referida análise, que pode ser feita pelo juízo, sendo desnecessária o intermédio de perito.

No mais, não sendo pleiteadas outras provas, tenho que o feito admite o julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, I, do CPC.

1 – Impugnação ao valor da causa

A Requerida impugnou o valor da causa, alegando que o valor dado à causa é muito superior ao valor do medicamento pleiteado e do valor requerido a titulo de indenização por danos morais.

Analisando os autos, verifica-se que o valor do medicamento requerido é de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e o valor da indenização por danos morais requerida é de de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Assim, tratando-se de pedido de fornecimento contínuo e por prazo indeterminado de fármaco, o Valor da causa que deve corresponder à prestação anual do medicamento, nos termos do artigo 292, § 2º, do CPC.

No presente caso, o valor da causa corresponde exatamente à soma da anuidade do medicamento, acrescido do valor requerido a título de indenização por danos morais, o que totaliza a quantia de R$ 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais), estando, portanto, correto o valor atribuído à causa.

Assim, rejeita-se a impugnação ofertada pela ré.

2 – Do Mérito

A requerida, como visto, é entidade fechada ou de autogestão, de modo que nas relações entre elas e seus beneficiários, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, inclusive, foi editada a Súmula 608 do STJ: *"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,* ***salvo os administrados por entidades de autogestão****"*.

Deste modo, não há se falar em incidência do CDC no caso em comento.

<u>No que tange ao pedido de obrigação de fazer (fornecimento de</u>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/01/2022 às 22:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0842800-02.2020.8.12.0001 e código Yg3xQqOg.

medicamento), tenho que o pedido autoral merece procedência.

Isso porque, malgrado a inexistência de relação de consumo, o contrato de plano de saúde por entidades de autogestão deve estar norteado pelos princípios do Código Civil, em especial o da boa-fé contratual, equidade, lealdade e cooperação, o que veta a conduta de práticas contratuais desleais, enganosas, desproporcionais e ilegítimas.

Além disso, a operadora de plano de saúde e a relação contratual entabulada estão sujeitas ao que dispõe a Lei 9.656/98 e demais dispositivos legais relativos à matéria.

Ressalte-se também que o contrato em discussão é de adesão, no qual não é assegurada ao aderente a discussão de seus termos, de modo que cláusulas contratuais podem ser consideradas abusivas, tendo por base os arts. 423 e 424 do CC.

Tal entendimento tem amparo no princípio geral da boa-fé que rege as relações em âmbito privado, pois nenhuma das partes está autorizada a eximir-se de sua respectiva obrigação para frustrar a própria finalidade que deu origem ao vínculo contratual.

Assim, a negativa de tratamento prescrito por médico especialista na área de tratamento da paciente, faz incidir o disposto no artigo 423 do Código Civil, que determina que as cláusulas ambíguas ou contraditórios devem ser interpretadas em favor do aderente.

Nesse sentido o TJMS:

> "E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI. OPERADORA DE PLANO FECHADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TIPO AUTOGESTÃO. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. RECURSO ESPECIAL N. 1285483/PB. NEGATIVA DE RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO PREVENDO A RESTITUIÇÃO. PROVA DE CREDENCIADOS NA LOCALIDADE. AUSENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DA CASSI NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR IMPROVIDO. De acordo com o entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1285483/PB, "não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo". **Ainda que não se aplique o CDC aos contratos de plano de saúde classificados na modalidade de autogestão, consoante disposição dos arts. 422 e 423, do Código Civil, há que se interpretar as cláusulas contratuais ambíguas ou contraditórias da forma mais**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/01/2022 às 22:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0842800-02.2020.8.12.0001 e código Yg3xQgOg.

> **benéfica ao contratante, sobretudo quando se tratar de plano de adesão, nos quais "são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.", nos termos do art. 424, do Código Civil**. Se o contrato de plano de saúde autoriza o reembolso de despesas médicas pelo aderente, é devida a condenação da operadora ao ressarcimento do valor dispendido pelo aderente do plano para a realização do tratamento médico indicado. A recusa do plano de saúde em ressarcir o contratante das despesas obtidas com o tratamento médico configura mero descumprimento contratual, sendo insuficiente, por si só, para a procedência do pedido de indenização por danos morais. "(TJMS. Apelação n. 0813489-39.2015.8.12.0001, ampo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 15/05/2018, p: 16/05/2018).

Fixadas tais premissas, no caso dos autos, nos moldes do laudo médico de f. 26 e receituário de f. 28, ambos **devidamente assinados pelo médico que acompanha a requerente (Dr. Amauri Ferreira Oliveira CRM 3931 MS – Especialista em Oncologia),** infere-se que a parte autora foi dianostigada com câncer de mama "*Neoplasia Maligna de Mama - CID C50.9, Estádio IV*", com realização de mastectomia (retirada da mama), **tendo o referido médico prescrito tratamento com o medicamento de uso contínuo Ibrance 125mg, haja vista que já fez uso dos medicamentos Zoladex e Tamoxifeno, porém apresentou progressão da doença (f. 26 e 28).**

Portanto, ficou devidamente comprovada a moléstia que acomete a autora e a imprescindibilidade do tratamento com o referido medicamento. Por outro lado, o plano de saúde não apresentou qualquer evidência a afastar a necessidade do tratamento prescrito, apenas negou o pedido sob o argumento de que o contrato não possui cobertura para o medicamento em questão, por ausência de previsão no rol da RN nº 428/2017, senão vejamos trechos da peça defensiva da ré (f. 111 e 114):

> Diante disso, o medicamento não está previsto no rol de cobertura mínima no Rol da ANS que teria expressa previsão contratual, de forma clara e em destaque no contrato firmado entre as partes. Portanto, denota-se claramente que, a operadora de saúde não possui obrigatoriedade de autorização e custeio do medicamento denominado "palbociclibe (IBRANCE)" ora requerido, eis que a requerida está amplamente amparada pelas cláusulas contratuais e na legislação vigente (Lei 9.656/98 e RN n. 428/2017).
>
> Neste sentido, resta demonstrado que o medicamento esta fora das Diretrizes de Utilização da Agência Nacional de Saúde – ANS, dessa maneira, em síntese e como corolário lógico, a requerida baseou-se no contrato firmado e no Anexo II da RN n. 428/2017 ao indeferir o medicamento pleiteado.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/01/2022 às 22:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0842800-02.2020.8.12.0001 e código Yg3xQqOg.

Não é demais ressaltar que qualquer restrição a procedimento considerado inafastável para o tratamento de moléstia coberta pelo plano de saúde é de ser considerada nula de pleno direito, porquanto, suprime um direito do contratante, sendo defeso ao plano de saúde questionar o tratamento prescrito pelo médico, sob pena de negar a finalidade precípua do contrato, o que fere a razoabilidade.

Ademais, o rol da ANS ou Anvisa além de exemplificativo, não pode restringir tratamento médico se há a necessidade premente para a realização do mesmo. É cediço que a ANS volta-se à fiscalização, organização e normatização dos procedimentos médicos, mas atua em caráter administrativo, sendo desvinculada das descobertas médicas e decisões neste sentido que sempre caminham na sua frente.

Assim, se a doença encontra cobertura no ajuste firmado (como é o caso, já que a autora é portadora de câncer de mama e o tratamento da referida moléstia está acobertada no plano de saúde contratado – fato este incontroverso nos autos), como ocorre neste caso, o tipo de tratamento a ser feito é aquele que for indicado pelo profissional da saúde eleito pela paciente.

Em outras palavras, se o tratamento da moléstia que acomete a parte autora está sendo prestado pelo plano de saúde, ele, em princípio, não pode se negar a fornecer os meios necessários ao bom resultado, tais como, a realização de terapias e procedimentos (se não são excluídas ou limitadas, repita-se), cabendo ao médico que acompanha o paciente ditar o tratamento mais adequado para o caso.

Não fosse isso, de acordo com o Parecer Técnico nº 28/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016[1], da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que trata da cobertura de medicamentos pelos planos de saúde é claro ao estabelecer que "*a Lei nº 9.656, de 1998, deixa explícito que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI),* ***<u>exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais e para controle de efeitos colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos</u>*** *(art. 12, inciso I, alínea 'c', e inciso II, alínea 'g')*".

No caso, como visto tanto do laudo médico de f. 26 indicou que o fármaco Ibrance 125 mg é o melhor tratamento no caso da autora, haja vista que ela já foi submetida a mastectomia, radioterapia, quimioterapia e fez uso dos medicamentos Zoladex e Tamoxifeno, porém apresentou progressão da doença; ou seja, **mesmo se tratando de fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, encontra-se tal exceção prevista na hipótese em comento, já que se trata de medicamento antineoplásico oral, além de que outros medicamentos não foram eficazes no caso da autora.**

[1] disponível em (http: / / www . Ans . Gov . Br / images / stories / parecer _ técnico / uploads / parecer _ técnico /_parecer_2016_28.Pdf), acesso em 23/11/2021.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/01/2022 às 22:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0842800-02.2020.8.12.0001 e código Yg3xQqOg.

Ademais, em recente consulta ao sítio da ANS[2], referida Agência Sumplementar ao atualizar o rol de procedimentos e eventos em saúde, na data de **24/02/2021**, com vigência da referida Resolução a partir de 01/04/2021, **incluiu na lista obrigatória dos planos de saúde o medicamento PALBOCICLIBE 125MG (IBRANCE)**.

De fato, compulsando o teor da noticiada Resolução Normativa, em seu anexo II, consta a inclusão, como "**TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CÂNCER**", do referido medicamento, vejamos:

64. TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CÂNCER

SUBSTÂNCIA	LOCALIZAÇÃO	INDICAÇÃO

ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar

SUBSTÂNCIA	LOCALIZAÇÃO	INDICAÇÃO
		(L858R) dos receptores do fator de crescimento epidérmico (EGFRS).
Palbociclibe	Mama	Tratamento do câncer de mama avançado ou metastático HR (receptor hormonal) positivo e HER2 (receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano) negativo, em combinação com inibidores de aromatase de terceira geração (anastrozol, letrozol ou exemestano) como terapia endócrina inicial em mulheres pós-menopausa; ou com fulvestranto em mulheres que receberam terapia prévia.

Neste contexto, ocorrendo no curso do processo fato superveniente relevante que atinja o direito controvertido da parte, cumpre ao juiz toma-lo em consideração, porquanto deve a tutela jurisdicional compor a lide da forma em que a mesma se apresenta no momento da entrega do arguido direito.

Inclusive, a este respeito, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou que "*o comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra*", pois "*consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir*" (RSTJ, Esp 1727063/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 02/12/2019).

Deste modo, com o advento do noticiado ato normativo, incluindo o medicamento pleiteado na inicial, qual seja, *Palbociclib (Ibrance)*, **no rol de procedimentos e eventos em saúde de cobertura assistencial**, o direito perseguido pela requerente mostra-se evidenciado, na medida em que o fármaco em questão passou a ser de **cobertura obrigatória pelos planos de saúde privados, incluindo aqui os de auto-gestão como é o caso da requerida.**

Por fim, ressalta-se que a modicidade das contribuições não pode servir de justificativa para a ré, posto que a autora paga as mensalidades do contrato de plano

[2] disponível em: https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=NDAzMw=, acesso em 23/11/2021

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/01/2022 às 22:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0842800-02.2020.8.12.0001 e código Yg3xQqOg.

de saúde para ser assegurada em caso de necessidade, de modo que não pode a operadora eximir-se da obrigação, frustrando as expectativas daquela, na hora que mais necessita.

Portanto, por qualquer ângulo que se vê, a procedência do pedido inicial de fornecimento do fármaco Ibrance 125mg é medida que se impõe.

Com relação aos **danos morais**, de acordo com o art. 186, do Código Civil *"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito*".

No caso, o ato ilícito se consubstancia na negativa da operadora do Plano de Saúde em fornecer o medicamento, indicado pelo médico que assiste à requerente, submetendo a parte a uma verdadeira *via crucis* para consegui-lo, o que inclui as investidas em sede administrativa, e até a propositura da presente ação judicial, lembrando que a autora claramente necessitava, com urgência do medicamento prescrito, visto que estava em tratamento para o câncer de mama, sendo que a houve a progressão da doença mesmo com a utilização de outros medicamentos.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 83 *"vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro de saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia o espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em situação de dor, de abalo psicológico e com saúde debilitada*." (**REsp 918.392/RN**).

Outro não é o entendimento da jurisprudência, conforme se destaca do julgado a seguir mencionado:

> *CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. DOENÇA. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DEVERES ANEXOS OU LATERAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1. O propósito recursal é determinar se a negativa da seguradora ou operadora de plano de saúde em custear tratamento de doença coberta pelo contrato tem, por si só, a aptidão de causar dano moral ao consumidor segurado. 2. Embora o mero inadimplemento, geralmente, não seja causa para ocorrência de danos morais, a jurisprudência do STJ vem reconhecendo o abalo aos direitos da personalidade advindos da recusa indevida e ilegal de cobertura securitária, na medida em que a conduta agrava a já existente situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. 3. A recusa indevida e abusiva de cobertura médica essencial à cura de enfermidade coberta por plano de saúde contratado caracteriza o dano moral, pois há frustração da justa e legítima expectativa do consumidor de obter o tratamento correto à doença que o acomete. 4. Existem situações, todavia, em que a recusa não é indevida e abusiva, sendo possível afastar a presunção de dano moral, pois dúvida*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/01/2022 às 22:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0842800-02.2020.8.12.0001 e código Yg3xQqOg.

razoável na interpretação do contrato não configura conduta ilícita capaz de ensejar indenização. 5. O critério distintivo entre uma e outra hipótese é a eventualidade de a negativa da seguradora pautar-se nos deveres laterais decorrentes da boa-fé objetiva, a qual impõe um padrão de conduta a ambos os contratantes no sentido da recíproca colaboração, notadamente, com a prestação das informações necessárias ao aclaramento dos direitos entabulados no pacto e com a atuação em conformidade com a confiança depositada. 6. In casu, o tratamento para a doença (neoplasia) por meio de radioterapia teria sido previsto no contrato, e a negativa de cobertura teria sido justificada pelo fato de o método específico de tratamento não estar previsto na lista de procedimentos da Agência Nacional de Saúde. Como a negativa de cobertura não estava expressa e destacada no contrato e como o tratamento seria necessário e indispensável à melhora da saúde, a recusa ao custeio do tratamento mostra-se injusta e decorrente de abuso, violando a justa expectativa da parte, o que revela a existência de dano moral a ser indenizado. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1651289/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 05/05/2017)

"O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que "a recusa indevida pelo plano de saúde à cobertura de procedimento/tratamento médico necessário à recuperação do segurado, ainda que fundada em cláusula contratual, por se mostrar abusiva, caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo da comprovação do prejuízo." (STJ - AgInt no AREsp 996042 / MG, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 09/02/2017).

No mesmo sentido, colhem-se julgados do nosso Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIAL – REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – LEI 9.656/98 – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que não sejam aplicadas as normas consumeristas aos planos de autogestão, os preceitos do Código Civil incidem sobre este tipo de contrato, em especial o disposto nos artigos 422, 423 e 424, sendo dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao restabelecimento da saúde do usuário aderente. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo, sendo indevida a recusa pelo plano de saúde. A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/01/2022 às 22:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0842800-02.2020.8.12.0001 e código Yg3xQqOg.

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico coberto e/ou de urgência, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. (STJ, AgInt no REsp 1647519/CE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017) (TJ-MS - AC: 08043232020198120008 MS 0804323-20.2019.8.12.0008, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 17/08/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2020)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXAME PETSCAN – EXCLUSÃO PREVISTA NO CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – COBERTURA CONTRATUALMENTE AJUSTADA – OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO E CUSTEAMENTO – DIREITO À SAÚDE – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DANO MORAL CONFIGURADO – PROVIDO PARCIALMENTE. (Apelação - Nº 0001618-05.2007.8.12.0008; Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 5ª Câmara Cível; data do julgamento 20/06/2013)

Assim, na negativa de fornecimento do medicamento indicado por médico especialista que assiste a paciente, o dano moral é presumido, em razão da medida abusiva da operadora de plano de saúde que pode agravar não só a situação física do paciente, mas também sua condição psicológica.

Logo, o pedido neste particular é **procedente**.

Por fim, com relação ao ***quantum*** indenizatório, dos autos se extrai que a autora é pessoa de poucos recursos e está realizando tratamento oncológico por longo período de tempo, inclusive com realização de mastectomia, sessões de quimioterapia e radioterapia, e utilizou outros medicamentos que foram ineficazes, tanto que a doença progrediu, de modo que a negativa ao fornecimento do medicamento lhe causou manifesto sofrimento desnecessário.

Não existindo parâmetros para a fixação do valor do dano, a indenização por danos morais deve ser fixada pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e punitiva ao ofensor

Feitas tais ponderações, entendo que o valor razoável da indenização por danos morais para o caso em apreço deve ser fixado em **R$ 10.000,00 (dez mil reais)**, cujo valor, por um lado, não se mostra baixo, assegurando o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais; por outro, não se apresenta elevado a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa.

Referida quantia sofrerá acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/01/2022 às 22:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0842800-02.2020.8.12.0001 e código Yg3xQqOg.

contados a partir da citação (art. 405 CC), por se tratar de relação contratual, corrigida monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362, do STJ.

3 - Dispositivo

Posto isso, com fulcro no art. 487, I do CPC, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** os pedidos formulados nesta *Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Indenização por Danos Morais*, proposta por **Viviane Gonçalves Vissoto Matos,** em face de **Unimed Campo Grande/MS – Cooperativa de Trabalho Médico**, para o fim de:

a) condenar a requerida a **fornecer à autora o tratamento medicamentoso com o fármaco "Palbociclib (Ibrance) 125 mg"**, na quantidade necessária e durante o período de tratamento expressamente recomendado pelo seu médico, conforme prescrição médica, tornando definitiva, assim, a tutela concedida na decisão de f. 40-47.

b) condenar a ré ao pagamento de **indenização por danos morais** em prol da autora no valor de **R$ 10.000,00 (dez mil reais)**, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (art. 405, do CC) e correção monetária pelo IGP-M/FGV, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Ante a sucumbência mínima da parte autora, condeno a ré ao pagamento integral de custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, e 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe e, em nada sendo requerido, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Campo Grande-MS, *data da assinatura digital*.

Vania de Paula Arantes
Juiz(a) de Direito

Assinado por Certificação Digital

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/01/2022 às 22:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0842800-02.2020.8.12.0001 e código Yg3xQqOg.